

引用格式:左冰.从景观到景像:数字时代吸引资产权再探讨[J].旅游学刊,2024,39(2):31-48.[ZUO Bing. From landscape to spectacle: A further discussion on the attraction property rights in the digital age[J]. *Tourism Tribune*, 2024, 39(2): 31-48.]

· 深入学习贯彻党的二十大精神 ·

从景观到景像:数字时代吸引资产权再探讨

左冰

(中山大学旅游学院,广东广州 501275)

[摘要]在注意力经济时代,地方文化以及景观所承载的吸引价值已经商业化成为具有文化和经济双重属性的吸引资产。由于景观的广域性以及文化的集体创造特征,限制了使用知识产权工具保护其产权人财产权利的作用。数字技术推动下,越来越多的文旅吸引物向数字化转换,关于它们的所有权和用益权问题日益严峻,亟须突破现有知识产权框架,以前瞻性的法律方式建立起保护吸引资产权益的治理体系。文章意图贯通从现实吸引资产权益产生到吸引资产形成,乃至其数据资产生成的全过程。文章在回顾国际上关于文化财产权利保护的研究进展和相关争议的基础上,剖析了知识产权难以保护集合性吸引资产权益的原因;继而将旅游吸引物权扩展为范畴更广的吸引资产权概念,阐释了吸引资产权与知识产权之间的互补关系。文章进一步从吸引资产权与观景权形成互换性利害关系的角度论证了吸引资产权设立的合理性与必要性,剖析了吸引资产权的适用条件、应用原则与制度基础,最后结合数字化背景对吸引物数字复刻后的数据产权归属进行了讨论。文章推进和深化了对旅游吸引物权的理解,为应对未来数字社会中的相关财产争议提供了法律解决方案,有助于推动文旅深度融合和数字文旅产业有序发展。率先认可吸引资产权的法定权益,可以成为中国对世界文化和传统知识保护的有益制度贡献之一。

[关键词]文化财产;吸引资产;知识产权;观景权;数字复刻;数据资产

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2024)02-0031-18

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2024.02.009

0 引言

想象一幅场景:一批游客购买了世界遗产地云

[收稿日期]2023-07-21; **[修订日期]**2023-10-16

[作者简介]左冰(1973—),女,四川宜宾人,博士,教授,研究方向为旅游经济与金融、文化与旅游贸易、红色旅游与可持续旅游,Email: zbing@mail.sysu.edu.cn,通讯作者。

南元阳阿者科村的门票,并在村里进行了大量的自由拍摄。回程后利用所拍摄的资料在增强现实、虚拟现实和其他创新技术支持下,设计制作了阿者科3D仿真云旅游软件并进行售卖。消费者在家中使用可穿戴设备即可欣赏阿者科的秀丽风光,体验云上旅游乐趣。阿者科村民也需要支付相同的费用才能获得观看体验。那么,这批游客的行为是否构成侵权?如果侵权,侵犯的是什么权利?谁的权利?

注意力经济已经构成了当代社会生活和商业运作的基本逻辑^①,而数字技术^②则是支持这套逻辑系统的重要媒介和经济工具。在数字技术支持下,生活世界中的旅游景观(landscape)已经脱离其物理背景,转变成为无时空限制的数字虚拟景像(spectacle),成为吸引互联网和社交媒体大众眼球和注意力的最有商业价值的资源。世界各地的文化资源,包括各类物质和非物质文化遗产、民间文化和表达以及当代创造物等也正在以数字文件的形式诞生。它们在市场上可被定价、购买、流通和交换,成为具有商品属性的吸引资产(attraction property),经数字复刻后,还可进一步被挖掘、设计和加工成为数字产品,成为具有增值潜力的数据资产,为开发机构带来新的利润空间。

在将吸引物转换为数据资产继而积累数据资本的过程中,对原初吸引物(real-life attraction prototype)的争夺是最为关键的环节。因为,它们是打造注意力所需的原始资本,也是构筑未来商业开发模式的重要文化材料(文化矿藏)。从地方知识、文化表达、文化遗产以及各种景观中汲取灵感,产生创新和创意是许多商业机构常用的策略^③。特别是在全球文化自由贸易政策和互联网支持下,人们免费获取、改编,甚至挪用和盗用形成创意的文化

^①包括数字摄影、音频和视频,以及用于野外记录的电子地图和地理信息系统、社交媒体和数字档案的计算机文字处理程序等。

材料更加容易^[3]。一个机构所掌控的吸引资产的数量越多,覆盖范围越大,可供模仿、借用、挖掘以增值的材料越丰富,在商业市场上的竞争力越强。正因如此,世界发达国家和大型跨国公司正在掀起一场类似工业革命初期圈地运动式的文化积累浪潮。争夺世界各地的文化和旅游吸引资源,并将其转变为自身所控制或拥有的数字吸引资产,已经成为这场文化圈地运动的核心策略。

出于经济目的,许多商业机构或数字平台既不承认其文化创意或吸引资产的创新来源,也不与其所有人或托管者分享经济收益,使得吸引资产所有者的权利受到严重侵害,导致社会冲突不断。这类冲突不仅在国内的文化和旅游开发中存在^[4],在国外也有诸多案例。例如,由于遭到严重文化威胁,埃及的立法机构正在制定措施以限制其国内某些古代遗址和图像的复制品的商业流通^[5];加拿大不列颠哥伦比亚省多伊格河第一民族决定将他们的数字文化遗产元素置于公共流通之外,以维持本民族保护其独特遗产的力量^[6]。前述“数字阿者科”作为阿者科村旅游的数字衍生品虽然是笔者的杜撰,但它折射出当前旅游和文化领域数字化应用开发时的社会现实,同时也反映出在将地方文化材料和人文景观转变为数字景像和数据资产过程中可能面临的所有权争议。

从基于社区的旅游开发的角度,笔者和保继刚曾提出了“旅游吸引资产用益物权”(tourist attraction property rights,简称旅游吸引物权)的概念^①,呼吁从法律上认可这一权利^[4,7-8],以保护社区拥有的旅游吸引资产的财产收益权。尽管论文在发表后产生了不少争议^[9-12],但也得到不少研究者的认可,并在阿者科村的旅游扶贫实践中得到应用^[14]。近年来,国际社会对文化遗产的数字所有权的争议,以及二战后国际社会关于土著传统知识和文化财产权的广泛而持久的讨论,使得从法律上承认吸引资产权日益急迫和必要。

产权清晰是形成市场交易、将资源转变成成为资产的前提条件。鉴于地方文化财产权益保护问题日益迫切,同时,基于当代社会中图像、影像或事物所产生的意象化图景正在取代人之真实感性生活的社会现实——旅游景观已经被抽象化为一系列足不出户即可观赏的数字图景,旅游语境中的人地关系和人人关系(如东道主-游客)已经因环境背景的抽离而产生了分离——需要将讨论从旅游吸引物权进一步延伸、扩展为具有更广域范畴的吸引资

产权及其数字化后的数据产权。亦即,需要将讨论从旅游领域延伸至生活世界和虚拟世界中任何能够吸引大众注意力并可加以商业利用的文化对象^②。因为,在数字化的时代,即便传统的跨越空间的旅游不复存在,但吸引物景像仍然可以通过网络进行传播和传递,成为吸引消费者眼球的资产。

本研究意图厘清从现实吸引资产权益产生到吸引资产形成,及至其数据资产生成的全过程中的权属关系。尽管在数字技术支持和受众的追捧下,“影像胜过实物、副本胜过原本、表象胜过现实”^[15],但它们终究不过是“拟像”。要厘清数字吸引物的财产权属,必须回到“拟像”形成的现实基础,首先梳理清楚客观世界中的各类吸引物权属问题,继而才能判析其数字化后的财产权益归属。为了保持研究的延续性和方便理解,本文讨论的重点将集中于文化和旅游领域。本文共分为6节。第1节介绍国际上保护和利用地方文化财产的进展与相关争论;第2节讨论基于知识产权制度或非确权合同形式开展文化财产保护面临的困境,同时从理论上回应争议者提出用知识产权框架替代吸引物权的意见(见张琮和张德森一文^[9]);第3节在厘清吸引物概念,以及剖析景观利益和吸引资产权的关系的基础上,从观景权以及权利义务统一原则出发,阐述设立吸引资产权的必要性及其对维护观景权和完善环境权的重要作用;第4节论述吸引资产权的适用条件、应用规则与制度基础;第5节探讨数字吸引物的数据权属问题;最后是全文总结和政策建议。

1 文化财产权利保护国际进展及其争议

1.1 文化财产权利保护:从人权到知识产权

2013年,耐克公司推出的一款黑白印花紧身裤因图案酷似澳大利亚和新西兰萨摩亚社区的传统 Samoan Pe'a 男性纹身而激起当地土著民众的强烈

①从其本身的概念界定出发,“旅游吸引物权”应读作“旅游吸引物-权(利)”,亦可做“旅游吸引物-权利”,不可读作“旅游吸引-物权”。旅游吸引物权属于产权人的用益性资产,属于用益物权之下的一个独立的次级类型,全称为旅游吸引物资产用益物权,英译为 tourist attraction property rights。如果将“旅游吸引物权”读做“旅游吸引-物权”,这将使其被误解为一种在层级上与“对物权”(iura in rem,简称物权)平行的权利关系类型。在法律上,与“对物权”相同层级的只有“对人权”(iura in personam)。为免误解,本文在写作中将其重新命名为“吸引资产权”。而造成这一误解的原因主要来自 attraction 的中文译名,详见3.1节的注释。

②非文化对象例如地质、地貌等不属于人类心灵创造,因此在本文中不予以讨论。但自进入“人类世”以来,地球上再难找到脱离人的活动的客观存在物。

不满;萨摩亚社区居民认为,耐克公司不恰当地使用了本民族的文化项目和表达,侵犯了他们的文化权利,并违背了《联合国土著人民权利宣言》(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP)^[16],以下简称《宣言》。耐克公司迫于压力最后召回了此款产品。实际上,这只是近年来出现的涉及西方殖民国家的原住民(indigenous peoples,常被译为土著或土著人民^①)的大量文化权利案例之一。在这些西方国家,从殖民时代以来,土著人民的传统知识和文化财产往往被视为一个公共领域。土著人民对于在他们的土地上进行的文化研究以及传统知识的挖掘几乎没有发言权,亦很少从中受益。从纺织、设计、音乐,到时尚、电影和制药等行业,国际上普遍且持续存在对土著知识和文化表达的盗用行为^[17]。1957年,联合国国际劳工组织(International Labour Organization, ILO)公约首次承认“土著和部落”人口为国家公民;1989年,在《土著和部落人民公约》中进一步确认了土著人民参与影响其遗产、传统领土、生活方式和身份的活动的权利,认可土著人民有权按照传统的土地保有模式保持与自然资源的和谐的关系^[18]。土著人民的价值体系、知识和文化生存权由此才得到承认^[19]。

关于土著人民的文化权利、传统知识、遗传资源及其保护的讨论首先出现在民族植物学研究中^[20]。20世纪70至80年代,西方药理学家在生物多样性丰富的土著社区和发展中国家寻找可以开发成新药物的物质以获得生物技术创新。这种利用地方传统知识找寻新药物的行为被称为生物勘探。随着跨国公司的进入,生物勘探变成了一个利润丰厚的行业,引发了一波剥削浪潮,被发展中国家批评为生物盗窃行为^[21]。考古学家和人类学家的“传统使用研究”也引起了不少担忧^[22]。民族志档案记录使得根植于地方的有形或无形的遗传资源和知识从它们的文化和环境背景中移除,成为文献文件,进而被其记录者占有和控制,成为记录者的知识产权。这使得代理、出版、分发、出售这些民族志对象的文化财产的合法权利掌握在记录者手中,而不是掌握在民族志研究的主体(当地居民)自己手中。土著人民和发展中国家的代表认为,这种行为是对他们的传统知识和遗传资源的殖民盗窃,从而引发了关于研究成果的所有权和使用权问题的国际讨论,以及土著社区及其后代对其传统知识和文化信息的所有权主张^[23]。

文化财产权利保护问题往往集中在发展中国

家以及西方发达国家的土著人民,并与西方国家的殖民历史深刻关联。1982年,第一届联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)世界文化政策会议发布的《墨西哥城文化政策宣言》提出,文化“不仅包括艺术和文学,也包括生活方式、人类的基本权利、价值体系、传统和信仰”;文化遗产被定义为“反映人类思想和工艺的创造性的所有事物”^[24],它既包括有形的文化遗产,即具有独特意义的历史文化、艺术和科学价值的物质实体,也包括无形的文化遗产,即世代相传的、具有部族身份特征的智力活动成果^②。由于当代社会物化、商品化和旅游化的过程把文化和文化遗产变成了可用于牟利的贸易产品,使得文化以及文化遗产成为商品经济社会中的“文化财产”。从而,保护土著文化权利的一个重要方面就是保护其“文化财产权”(cultural property rights)^[25]。

按照西方的财产制度,文化财产需要保护的程 度,取决于它形成集体表达和身份认同等文化权利的物化程度^[26]。对于物化的遗产,相对易于界定其所有权归属,而传统知识和非物质文化遗产因其无形性被纳入了知识产权(intellectual property rights)范畴。1992年,联合国制定了《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity, CBD),以下简称《公约》,寻求公平解决谁拥有或受益于现存土著群体文化知识和研究成果的问题,以明确利益相关者的权利和责任。《公约》倡议,土著人民过去(现在仍然)拥有其遗产的所有权,包括传统知识、图形图像的使用和其他相关的文化表达^[27]。2001年,世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization, WIPO)成立了知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会(The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, IGC),以制定保护土著人民和当地社区传统知识、文化表现形式和遗传资源的法律文书。2002年,

①土著人民是指拥有自己的文化模式、社会制度和法律体系(可能程度不同)的民族。

②文化遗产的概念经历了从物质资产到无形资产的转变,其概念不断扩展。艺术、历史和纪念性遗产继续作为文化遗产的核心类型,同时也将文化表达和表现形式等非物质文化遗产纳入其中。按照 UNESCO 的定义,非物质文化遗产包括社区、群体和在某些情况下个人承认为其文化遗产组成部分的习俗、表现形式、表达方式、知识和技能。包括:口头传统以及作为非物质文化遗产载体的形式和语言特征以及传统地名;表演艺术;社会习俗、仪式和节日活动;关于自然和宇宙的知识和实践;传统工艺;烹饪、烹饪准备(过程)和食品;自然景观的具体用途;集体社会化和组织形式;声音(声景)、音乐和传统舞蹈。可见其范围非常广泛。

WIPO和UNESCO共同编撰了《保护传统文化表现形式:条款草案》文件,旨在立法规定传统知识和文化表达的传统权利和道德权利,并鼓励将土著人民习惯法和传统治理制度纳入国家知识产权立法^[28]。然而,这一国际文书对联合国成员国并不具有约束力,因为实施公约所需采取的措施,包括立法、制定政策和组建机构等,必须符合成员国各自的法律和制度规范^[20]。

2007年,《宣言》进一步扩大了对无形文化权利的保护范围。《宣言》第31条指出,土著人民对其传统知识、传统文化表现形式、环境保护形式和遗传资源及其相关知识产权享有权利。这些权利包括:1)振兴、使用、发展并向后代传递他们的历史、语言、口头传统哲学……为社区、地点和个人指定并保留他们自己的名称;2)维护、保护和发展其过去、现在和未来的文化表现形式,如考古和历史遗址、文物、设计、仪式、技术、视觉和表演艺术和文学;3)维护、控制和开发他们对这些文化遗产、传统知识和传统文化表现形式的知识产权^[29]。然而,基于西方自由主义法律体系的知识产权法在很大程度上难以保护土著人民的文化权利。这是由于,土著人民的文化权利是一种基于共同的血统、民族或宗教的集体主张;其文化财产不是个体的创造,而是涉及从过去到未来的集体生产、创造、传播和继承的问题^[22,30]。土著人民基于集体所有观念的文化财产权,与基于个人主义的西方知识产权之间存在不可调和的矛盾和冲突^[3,5-6]。

1.2 数字化导致冲突加剧

随着数字技术的飞速发展,各类文化遗产、传统知识以及文化表达正在以一系列媒体文件的形式制作和共享,供不同的网络公众使用。博物馆藏品被拍摄下来并在网上展览;非物质文化遗产也被以保护的名义记录成为数字档案或数字遗产。UNESCO将“数字遗产”定义为:“人类知识和表达的独特资源。它包括文化、科学和行政资源,以及技术、法律、医疗和其他各种以数字形式创建的信息,或从现有模拟资源转换为数字形式的信息。”^[31]数字革命极大地提高了个人和商业机构从地方文化和知识中获取资源、材料并获利的能力,同时也导致数字文化材料的流通、传播和利益分配问题变得越来越紧张。在加拿大,当Dane-ziaa社区成为民族志研究者的对象后,社区的文化遗产变成了民族志档案、影像资料等实物文献。而这些民族志文献

被数字化之后,Dane-ziaa社区的文化遗产随之又成为数字遗产,以数字文件格式存储在设备中,其版权归属于Ridington数字档案馆的收藏家。虽然其收藏家声明与4个Dane-ziaa社区共享版权,并且可以提供给Dane-ziaa社区成员免费使用,但该批文献的数字版权并没有从收藏家手中转移给其共同所有者(社区),因而这批数字档案实质上属于收藏家的财产^[32]。

这个案例呈现出地方文化财产在文献化、数字化过程中的一个根本性矛盾——集体拥有的传统知识、文化和景观通过文件行为(文献化或数字化)可以转变为个人或机构的财产,继而被加以商业化利用。正如本文开篇所假想的数字阿者科旅游情境:人们在数字阿者科进行云旅游,可以一次性体验春夏秋冬美景,360°无死角、多尺度地尽情观赏,其体验也许比到阿者科在地旅游更丰富,并且,人们无需支付交通、住宿和门票费用,进行数字阿者科旅游的成本极低^①。问题在于,创造和维持此文化景观原型的阿者科村民却失去了财产权利,享受不到任何收益。现实中的文化景观可以被认为是当地人民的文化创造,但数字化使得根植于地方的文化景观从生成它们的环境背景中被剥离,就像文件被选择、记录和存档一样,成为了抽象的符号和计算机代码。当阿者科的美景成为被程序和新媒体制作的数字化对象,然后由他人管理和访问时,按照现有的知识产权法,这个文件化和影像化(即物化)的过程与阿者科村民无关,因而不能成为阿者科村民的财产(知识产权)。这种矛盾在Dane-ziaa社区的传统文化文献化和数字化过程中得到了充分体现,也将在未来各类云旅游、数字旅游情境中展现。

在《自由文化》一书中,Lessig指出,互联网“为许多人释放了非凡的可能性,让他们能够参与到建设和培育远远超出当地边界的文化的进程中”^[33]。几个世纪以前,地方性的思想、歌曲、舞蹈、表演、仪式和景观不需要任何产权保护,因为当地居民对他们的文化财产保持着物理上的控制。人们必须实地观看和体验,从而产生了旅游活动并形成了旅游吸引物概念。然而,新的记录媒体如博客、抖音、论坛等拓宽了记录和使用文化信息的手段。数字流通机制使地方文化财产的利用和保护变得更加复杂:人们可以轻而易举地获得未经授权的图片、视频、知识和文化表现形式的复制品;数字技术的再

①这是由于数字产品的边际成本接近0。

现性也使这些物品和地点(以及它们所包含的信息)可以在不实地访问它们的情况下被查看、欣赏、改编、重组以获得商业利益,并且无需与其文化监护人分享经济收益^[23]。

新自由主义思想推动下的全球文化自由贸易政策使得这种情形进一步复杂化。UNESCO在《保护数字遗产宪章》(Charter on the Preservation of Digital Heritage, 简称《宪章》)中强调,要确保最大限度地让公众获取通过UNESCO项目编码的“世界记忆”或“全民信息”,“对数字遗产材料的利用,特别是那些公共遗产,应该是无限制的”^[34]。虽然《宪章》同时也提出,数字遗产材料中敏感的及个人的信息应受到保护,以防止任何形式的侵犯。然而,这里的关键问题是,敏感材料或个人信息与适合在公共领域传播的数字遗产有何区别?如何决定(数字)文化遗产的开放性或封闭性?对此,文化国际主义者和文化民族主义者展开了激烈的争论。

1.3 文化国际主义与文化民族主义之争

从文化的广域性和知识的公共产品属性出发,传统知识和文化表达可以被认为是一种免费可用的智力资源。从有效利用资源的角度,不少研究者认为,解除对知识使用的许可和对信息自由流动的禁令,可以刺激研究和创造力,促进经济增长;因此,对文化财产以及遗传知识的利用应以公共利益为依据,因为这符合公众的利益。例如国际科学和研究机构一致认为,传统知识、植物基因技术遗产和更加广泛的生物资源,应该被视为“人类共同遗产”和全球“公共领域”的一部分,可以自由地加以利用以促进研究和创新,推动全球知识基础设施的发展^[35]。互联网、数字地图等创新公共物的出现,也使得人们普遍赞同关于自由文化公地的观念。一些有影响力的数字技术应用,例如安卓系统的开放获取,以及促进互联网信息自由的开放倡议和项目也加剧了“数字民主化”进程^[36],使得开源和知识共享的观念深入人心。它们对知识产权框架下的“授权”观念构成了挑战。在这种情形下,不仅发达国家和跨国公司希望将文化和生物多样性丰富的地区置于国际“公共领域”之下,即便是非营利机构因信息的敏感性而限制某种知识或文化项目的使用,也可能被大众批评为不考虑公共利益或不够民主。

但是,土著人民和发展中国家的代表认为,工业化国家从发展中国家获取“原始”生物种质,对其进行操作和提炼,并将其作为符合专利保护资格的

科学发明卖给他们。这完全是对土著人民传统知识和物种资源的殖民提取^[37]。因为从发展中国家收集的原始种质在许多情况下是土著人民许多代人共同努力的成果,它们“不是自然的免费礼物,而是数百万小时人类劳动的产物”^[38]。不仅如此,将文化视为公共领域,实际上创造了一种负面激励,它促使人们免费获取和自由使用非创造者和文化所有者的文化材料或文化原型。这会否定和抹杀当地人民历史上的知识、文化和技术成就,加剧当地人民与发达国家在财产权方面的不平等。

文化民族主义者从而认为,对“文化公地”和“共同遗产”概念的随意使用无异于殖民行为,这将使发展中国家的文化和遗传资源成为可以被自由占有的无人区^[37-38]。不加批判地接受文化遗产和传统知识是人类共同遗产的观点在殖民国家是有问题的,因为它冒着重现殖民政治的风险^[39]。共同遗产主义“可能在直觉上很有吸引力,但即使实现了,也不一定会给第三世界国家带来物质上的好处”^[38]。从全球来看,很难找到生物勘探对土著社区的社会和经济发展真正作出过贡献的案例^[37-39],即便是研究者创建民族志档案以整理和保存地方知识、无形文化表达或口口相传的故事的行为也远非中立。土著人民并不特别渴望成为全球公地的一部分^[40]。

1.4 情境实用主义者的折中方案

文化国际主义者和文化民族主义者之间的紧张关系显示出土著人民对其文化财产的捍卫和关于知识集体所有的信仰,与西方社会对公共知识的公平使用以及对个体知识产权保护的观念直接相冲突^[36]。一些研究者进而怀疑国际上关于土著人民的知识产权提案的有效性,认为双方必须仔细考虑各自立场的全球影响,需要探索“对土著人民的科学知识的商业使用进行补偿的基本机制”^[22],权衡土著人民享有专属于他们的文化财产的特殊权利对人类普遍持有的公平观念的有害影响,以达成适当的妥协。

为了解决“遗产作为全人类的资源,与作为适当属于其起源社区的事物之间的平衡”^[36],有研究者提出应采用情境实用主义的方法,即地方社区和商业机构之间可以结成许可伙伴关系,通过提供公平补偿以分享利益^[42]。这种折中方案得到了许多学者的赞同。赞同者认为,共同管理意味着一种妥协的意愿,这对于持不一致态度的各方之间达成可行的协议至关重要^[41]。基于共同管理的框架比基于权利

和规则的模式更可取,可能比扩大知识产权法更有效。即便在实践中,联合管理的基础很难在试图将土著知识用于商业目的公司的掠夺性活动中找到,但公众的广泛同情将使土著人民在世界舆论法庭上具有相当大的影响力,这可以用来迫使相关公司遵守基本的道德标准。例如斐济语言和文化研究所的文化测绘计划创建了一个关于贝卡(Beqa)岛萨瓦乌人(Sawau)的故事、遗址和共同记忆的档案,以防止滥用、误读和误解萨瓦乌文化遗产^[43]。萨瓦乌项目的视听文件仍然使用斐济语,仅向萨瓦乌社区成员和研究所的研究人员开放。如果公众想要查看和使用这些信息,必须获得萨瓦乌人祭司氏族首领和斐济语言和文化研究所的共同许可。在加拿大和新西兰,也有许多组织采用这种研究者和社区共同管理的模式,以帮助保存土著文化遗产和知识,并促进全球社区和机构之间的互惠的知识交流^[44]。

尽管共同管理的框架具有一定的社区控制性,但它忽略了在利益分配和谈判过程中权力关系不平等的现实,以及日益扩大的数字鸿沟问题。在世界不同地区,有文化、技术、能力和信心参与各类文化项目的社区成员差异很大。金钱、权力和社会资本的距离使得公共领域对某些公民来说比其他人更容易进入和利用。正如联合国开发计划署(The United Nations Development Programme, UNDP)所指出的:“传统知识的持有者和使用者之间签订私人合同的一个主要缺点可能是土著社区与其对应方在议价能力、资源、获得法律咨询和谈判技巧方面存在巨大差距。”^[45]就此而言,共同管理框架可能会提供一种虚假的、暂时的安全感,因为文化价值分配的过程,以及随之而来的资源分配的过程,不是一个中立的过程,而是一个紧张的权力斗争的场所,以及一个关于身份、品位、阶层和价值观的复杂的政治场景。

2 知识产权制度及其困境

如前所述,为了抵制新自由主义向土著文化的扩张,法律专家和国际组织建议通过大幅扩展知识产权框架来保护土著文化,并屏蔽某些形式的知识和信息。国内一些旅游研究者也提出了从知识产权角度寻求对旅游吸引资产权益进行保护的观点^[46]。这些提议尽管有其合理性,但忽略了在文化生产中和在不同的社会模式下,知识产权作为被动防御体系的作用非常有限的事实。

2.1 不可调和的价值观冲突

知识产权法起源于英国1710年的《安妮法令》,它是基于18世纪欧洲以个人为中心的财产、劳动和所有权的概念^[47]。对知识产权进行保护的理由基于知识、成果或文化表达可能产生财产价值,侵权会造成创作者的经济损失。由此才产生了创作者所有权保护和货币化知识产权的特定“权利”^{①[48]}。西方社会对知识产权的保护通常以创作者身份为前提,以法律文书形式予以承认,并通过严格审查的方式支持^[49]。知识产权相关法律文书保证创造者或发明者无论创造什么都拥有永久的创作权(精神权利),并在一定时间内享有其创造或发明物的垄断权和专有权,以控制其创作成果的复制、分发、消费以及商业开发。在知识产权制度下,当民间故事、传统观念、歌曲、舞蹈、地方知识没有被整理记录为档案文件时,这些无形的文化财产将不被视为具有知识产权,从而得不到法律的保护。正因如此,前述以书面、音频或视觉形式记录的Dane-ziaa社区的知识和文化资源,才合法地成为民族志研究者和他们工作的机构的受保护的知识产权,而不是土著社区的文化财产。

在土著人民看来,西方知识产权制度,特别是版权的设立所依赖的理念并不能反映出知识产权客体及其产生的权利^[29]。这是由于,土著人民和大多数发展中国家人民认为,传统知识和文化遗产是集体性质的创造性生产实践成果,是祖先和社区共同拥有的集体成就。社区只是文化财产的“托管人”而不是“所有权人”^[47]。不能将传统知识或文化遗产从社区取出,并向其托管人提供独家知识产权或相关权利保护。土著人民习惯法所隐含着的文化财产公有且永久所有的制度与西方自由主义法律体系下知识产权的“占有个体主义”形成了根本性的冲突^[50]。

更进一步地,在西方知识产权模式下,人类所创造的产品(例如书籍)可以与其创造者(例如作者)分离。这种观念的形成基于西方自然/文化两分的本体论。在这种本体论思想下,精神与物质可分

①联合国《建立世界知识产权组织公约》(1979年修正版)规定:“知识产权包括有关下列项目的权利:文学、艺术和科学作品;表演艺术家的表演以及唱片和广播节目;人类一切活动领域内的发明;科学发现;工业品外观设计;商标、服务标记以及商业名称和标志;在工业、科学、文学或艺术领域内由于智力活动而产生的一切其他权利”^[48]。从统计目的出发,一般将知识产权资产分为3类:版权,如文献著作、艺术作品或歌曲;专利,指有形资产领域的技术发明;商标,包括地理标志、品牌标志、商号等。在知识产权框架下,对传统知识和文化创作的保护主要基于版权。

离,文化可以脱离它所依赖的环境,客观世界也可以被抽象化为一系列数字图景,并以电子文本的方式被收入囊中。而对于土著人民,这种做法无异于是将地图当成它所代表的领土^[32]。土著人民的整体世界观并不区分自然和文化维度。他们认为,传统知识和文化表现形式与地方不可分离,它们都是整体文化系统的一部分,与社区的社会结构内在交织在一起。正如WIPO在一份报告中所指出,“一首歌不是一种‘商品’或一种‘财产’,而是人民与其领土之间一种古老而持续的关系的表现形式之一”^[51]。在土著人民看来,“文化财产实际上是一种社会形式”^[52],其所有权不存在转让的可能性,对文化财产的捍卫是基于自身的社会关系和责任。这与西方财产范式强调异化、排他性和商品化存在认识论上的根本差异。

2.2 知识产权模式的治理困境

联合国的政策制定者试图通过在国家和国际立法中承认土著社区的习惯法来解决这个问题^[53],如联合国2007年通过的《宣言》第31条明确承认,土著人民拥有控制自己的传统知识的权利。然而,应用土著本体论和认识论来管理土著资源势必引发一个更严峻的问题,即是否承认土著人民习惯法和传统治理制度。这是由于,在国家立法中实施国际公约本质上依赖“国家”这个唯一具有真正决策权和执行力的行为体^[53]。然而,自19世纪以来,“民族国家的主权潜在地剥夺了社区和土著部落定义、确定和管理其非物质文化遗产的权利”,“在1648年《威斯特伐利亚和约》之后出现的国家主权体系中,很难为土著独立和自治留出空间”^[35]。

尽管UNESCO和WIPO倡导在国家立法中实施国际公约,并呼吁对土著文化权利进行知识产权监管,但土著法律在历史上因被殖民而被强加的西方财产制度所推翻。如果按照土著人民习惯法的保护形式,必然要求解除国家对传统上由土著和地方社区保管的遗传资源和文化财产的法律控制权。在历史上与剥夺土著权利紧密相关的法律体系存在的前提下,承认《宣言》《公约》《宪章》等国际法所规定的土著人民权利可能需要做出宪法性质的改变,这将对国家主权构成严重挑战^[35,53]。

例如《生物多样性公约》是全球签署国家最多的国际公约,但美国签署后至今未批准实施该条约。其原因在于,美国认为该公约会损害国家主权,并可能对其国内专利法造成潜在的干扰;而欧

盟则采取了中间立场,在发展中国家和土著社区,坚持抵制解决知识产权问题;澳大利亚也将土著知识产权问题作为“红线”^[54]。可见,在知识产权法律框架下,利害攸关的不仅仅是文化财产的分配,而是应该采用谁的本体论体系和治理制度的问题。

3 景观利益、观景权与吸引资产权

3.1 景观与景观利益

上述关于文化财产权的争议的核心实质上是商业利润分配及其控制问题。这是由于在当前这个注意力经济时代,独特的文化知识、文化表达以及人文景观能够成功地吸引消费者的关注和价值认可,成为具有文化资产和经济资产双重属性的吸引物(attraction)^①。按照剑桥词典的解释,attraction是指“能够让人们想去一个地方或做一件特别的事情的因素(something that makes people want to go to a place or do a particular thing)”^②。它无边界的限制,包括各种有形无形的因素,可以是某一客观事物,如一幅画,可以是某个空间场所,如一座山或某个村落,也可以是无形的知识和文化习俗。任何物品或因素之所以具有吸引力,无不因其可满足人们的健康、审美、娱乐、教育或逃避等需要。文化符号、景观、物体也好,人物、事件、活动也罢,或者是前述传统知识或非物质文化遗产以及虚拟景像,都是吸引物存在的不同形态^[55]。当这种因素吸引的是异地的旅游者,则成为特定的旅游语境下的旅游吸引物。

独特的自然和人文景观、良好的环境也是旅游与生活中重要的吸引物。2000年,《欧洲景观公约》将景观定义为:“人们感知到的、自然因素和(或)人为因素作用及相互作用结果为特征的区域”^[56],并认

①在中文语境中,attraction通常被译为吸引物,并已被学界和业界广泛接受和使用。按照《新华字典》的解释,汉字“物”有多重含义,常用于指人以外的具体的东西;也有“内容、实质”之意,如“言之有物”。中国古代典籍如《诗经》《左传》中也曾将“物”用于指代事情、符号、标记或神灵等。因此,“物”既可以是无形的也可以是有形对象。如果取其“内容、实质”之意,将英语attraction翻译为吸引物(即吸引质)无疑是准确的。由于法律上所谓的“物”,是指存在于人身之外,能够满足人们的社会需要而又能为人所实际控制或者支配的物质客体。因此,在使用吸引物概念时,可能难以让人将它与事件、活动、景像等抽象和无形的事物联系起来,这是造成许多误解的重要原因。因此有不少研究者逐渐开始使用“旅游吸引”以代替“旅游吸引物”,以避免“物”字带来的误解。从习惯用法出发,本文仍然使用了“吸引物”的称谓。

②Cambridge Dictionary. Translation of “attraction” from the Cambridge English-Chinese (Simplified) Dictionary [EB/OL]. [2023-05-16]. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-simplified/attraction>.

为景观是自然和文化遗产的基本组成部分,为包括娱乐和旅游在内的经济活动提供了背景^①。作为复杂的自然-文化生态系统,景观蕴含着人与自然高度融合的生产方式与生活状态,它展示和表现了区域内人文思想体系的本质,具有生态、环境、历史、文化和美学等多重价值。如果我们把土地看作当地居民知识和思想表达的媒介,文化景观就是绘制在土地上的人类文化的在地思想表达形式,同时也是一种精神产品和文化欣赏的对象(吸引物)。

这种由于良好景观带来的精神愉悦感也是人的一种实际利益,即景观利益。从马斯洛的需要层次理论来看,审美的享受、文化和精神享受是人类社会发展到一定阶段的必然要求。从发展权来看,这是值得法律保护的,因为它符合人的自然需要。因此,世界各国均立法对公民享受由地域性、历史性、文化性要素形成的特定地区的客观状态的权利或利益,即公权性观景权加以保护。《中国大百科全书》将观景权定义为“公民自由欣赏自然景观和人文景观的权利,也称为景观权或眺望权”^②。

在美国、欧盟等发达国家,公权性观景权已被列入宪法和其他部门法,并应用于司法实践。如美国《国家环境政策法》(1969年颁布)第二条第二款明确:“保证为全体美国人创造安全、健康、富有生产力并在美学和文化上优美多姿的环境”^[57]。伦敦自1970年开始陆续实行法定战略性眺望景观保护,通过景观视廊、广角眺望景观协调区、背景协议区等分区控制手段,确保市民在城市内远距离欣赏美景的权利;巴黎根据视线与控制点的可见关系在市划出了45处景观控制点,以最大限度地维护公众享受美景的权利^[58]。日本政府在2004年公布了《景观法》《实施景观法相关法律》《城市绿地保全法》3项法律,明确指出,“良好景观是由地域之自然、历史、文化等与人们之生活及经济活动保持调和而形成者,故需对土地利用加以适当限制”^[57]。我国的一些城市如青岛、威海、成都等均出台了《城市风貌管理条例》或《城市景观风貌管理条例》,对具有地域特色与时代特征的景观和景观风貌区域进行保护和管理。

3.2 观景权与吸引资产权:一组权利/义务的对对应关系

上述各国以及我国对公民景观利益的保护主要涉及的是公权性观景权。这实质上是通过政府(土地所有权人)收税(权利)-规划管理和土地利用限制(义务)来完成对具有公共属性的景观利益的

保护;与之同时,公民纳税(义务)并拥有享受良好景观的(权利)。城市公园、博物馆、高校免费开放进入皆是此理。由此也引申出了一个问題:如果某些具有私权属性的景观或吸引物具有良好价值,其产权人投入劳动、时间和智力等成本创造或维护良好的景观和吸引价值,或者对该吸引物的利用进行自我限制,使其在相当长的一段时间内得以保持其状态和价值,为公众提供了景观利益和精神利益。产权人是否应得到经济补偿?产权人因提供了景观利益而获得的补偿价款是否也应该得到法律保护?

以阿者科为例,其成为世界文化遗产,使村民对地方文化、物质和精神资源的保有负有重大责任。阿者科居民选择将自己的文化景观商品化,开发成具有市场竞争力的旅游产品并维护其品质,这并非易事。除了日常运营外,村民需要不断地投入体力劳动和抽象劳动(创造力),以努力维护梯田景观和作物系统,同时,还需要对抗根据外部品味和消费模式包装文化遗产可能导致的文化退化。不仅阿者科,对于普通的旅游目的地或旅游场所,如果其产权人提供了景观价值或精神利益并承担了保全或创造良好价值的社会成本(义务),却不能获得相应的经济补偿甚至不能收回其为此所承担的全部成本(权利),这是否构成了一种不对等的权利-义务关系?

从马克思主义“劳动价值论”出发,“自己的劳动同样也表现为法律上的所有权证书”^[59]。因提供景观利益而获得其财产权具有劳动成果保护上的正当性,这符合正义原则。从社会发展现实来看,景观利益已经日益商品化为一种实际的私人财产利益。如在城市楼盘销售中,某住宅小区如果拥有良好和优美的景观可以给房产所有权人带来附加价值。研究表明,自然景观或环境质量得分每提升1%,将推动普通商品住宅价格上涨1.5%,保障性住宅价格上涨0.7%^[60]。这种派生利益具有私权属性,称为私权性景观利益^[57]。当利用地域性景观发展旅游时,景观的吸引价值通过市场交易也可以转换成为直接的经济利益,其方式包括收取门票将景观吸引价值直接变现,也包括某些隐蔽性的价值索取,例如酒店将“看得见风景”的房间价格设定为明显

①景观不局限于可能被认为是良好的或优美的景观,也包括日常或退化的景观。

②《中国大百科全书》(第三版网络版)[EB/OL][2023-06-23]. <https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=36634&Type=bkzyb&SubID=48678>.

高于其他同类客房的行为。这两种私权性景观利益的获得实质是在利用公权性景观利益的外部性,将其内部化为经营者自身利益^①。这正是笔者和保继刚最初提出旅游吸引物权概念的社会现实基础。

从景观利益的互换性利害关系出发,可以将景观权与吸引资产权^②定义为一组具有权利-义务上的对应关系的法律概念。如果公民享受景观利益的权利值得法律保护,那么缴纳维护景观的成本则是义务;如果维护文化遗产和保全景观是义务,那么收回为此付出的成本或获得相应补偿则是权利。从财产权来看,供给者因提供了景观价值或精神利益而产生的收益(吸引资产权)也应该得到法律保护。权利与义务对立统一。对于公权性景观,其权利主体是公民或某个地域范围内的全体居民;相应地,其义务主体是(地方)政府。政府收税(国税或地方税)并提供景观(吸引物),同时承担管理规划的职责,政府拥有吸引资产权。例如意大利威尼斯市宣布,从2023年1月16日起,对当天到达、离开威尼斯市中心和岛屿的游客征收进城费,就是在行使此项权利^③。同一逻辑,私权性景观权对应私权性义务。私权性景观的义务的主体是景观(或吸引物)的供给者,获得其许可的人才能被视为可享受景观权的主体。

私权性景观与公权性景观并非截然分开的。私权性景观的空间尺度通常较小,局限于个体/家庭或社区层面,例如阿者科村落或某个主题公园等。它们通常嵌入在尺度更大、层级更高的公权性景观吸引系统之中,从而形成空间或辖区上的多重产权嵌套关系。例如威尼斯城的景观就是由类型众多的私权性景观和尺度更小且多样的公权性景观共同组合构成的。它对于全体威尼斯人属于公权性景观,对于游客则属于威尼斯人集体共有的私权性景观。可见,观景权人和吸引资产权人的身份并不是固定不变的,因具体社会情境而不断变化。阿者科村民到北京街头漫游时,是公权性城市景观的权利人(我国城市土地公有);而北京游客到阿者科旅游时,阿者科村民则是其私权性景观的共产权人(阿者科土地集体所有且蘑菇房私有)。

4 吸引资产权:适用条件、应用原则与制度基础

4.1 吸引资产权的本质属性是财产权,归属用益物权 吸引力特性是判定某个现象或事物能否成为

吸引对象(物)的基本判定标准^[55]。在现实世界中,吸引力往往隐含或附着于某个或某种对象,如同客观世界存在的万有引力,人们无法将吸引力与其对象在物理上进行拆分。因此,吸引资产权作为吸引物所有者的资产权益的体现,具有从属性,归属于用益物权的次级类型,其本质属性是财产权。所谓的“旅游(景区)经营权”,实质上是吸引资产权益人将其吸引资产以合同的方式出质给开发商,特许经营其用于旅游经营。当然,产权人也可授权用于他途,例如将阿者科景观图片印刷在文化衫上,或编辑成图册出版。

吸引资产的权益归属与一国的土地和财产所有权制度紧密关联。土地方面,我国《宪法》第十条规定,“城市的土地属于国家所有”“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有”。虽然我国土地的所有权人只能为国家或者农民集体,但土地附属物却可按规定分别归国家、集体和私人所有。《中华人民共和国民法典》(简称《民法典》)第二编物权第五章进一步对国家所有权和集体所有权、私人所有权进行了详细而明确的规定和区分。其中,第250条规定,“森林、山林、草原、荒地、滩涂等自然资源,属于国家所有”,第251条规定,“野生动植物资源,属于国家所有”;第260条规定了集体所有的动产和不动产类型,并在第261条明确“农民集体所有的动产和不动产,属于本集体成员集体所有”;第262条规定,“私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有所有权”。关于文物和非物质文化遗产,我国《文物保护法》第五条规定,“中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有”。《非物质文化遗产保护法》第二条规定,“非物质文化遗产组成部分的实物和场所,凡属文物的,适用《文物保护法》的有关规定”。对于具有知识产权性质的标的物的权利,《民法典》中也

①除非经营者为此支付了景观成本,或其收入用于某种公共支付。

②如前所属,为避免“吸引物”译名中的“物”字可能带来的分歧和误解,本文使用了“吸引资产权”这个概念。从中文语言表达而言,“吸引物权”如果读作“吸引—物权”,则很容易与“物权”这个高层级权利束的概念混淆,被误解为是与之同级的物权类型。但如果表述为“吸引权”,似乎不能充分呈现吸引资产的权益属性。借鉴知识产权“出质”的说法,似乎也可以命名为“吸引质权”,此乃与读者共同思考。

③央视新闻. 威尼斯宣布从2023年1月起对游客征收进城费[EB/OL]. [2023-10-13]. <https://news.cctv.com/2022/07/02/ARTIX2rRhXKWfK-FGxKznZYNO220702.shtml>.

有诸多涉及知识产权及技术合同的相关规定^①。

由于任何事物或现象都可以产生吸引力,且这种因吸引力产生的收益具有依附性和从属性,因此,吸引资产权益归属在现有法律规定体系中已非常明确,即吸引资产的权益主体是吸引物的所有权人。对于公权性景观或吸引物属于国家或者农民集体所有的情况,个人不享有所有权,因此任何个人不能通过行使所有权的方式来自主地利用吸引物,需要依法通过赋权或设立相应的用益物权合同来满足利用吸引资源的需要。如兰州市印发《兰州市旅游景区特许经营管理办法(试行)》规定,兰州市行政区域内景区特许经营权由市政府统一管理^②。对于私权性景观或吸引物,其产权人享有财产权利。如果他人对吸引资源产生损害,在实践中其产权人具有诉讼的权利。若吸引物属于国家所有,则作为国家土地、文物和自然资源所有权代表的行政机关具有提起诉讼的身份;农村集体组织则是集体所有权法定的代表。对于非物质文化遗产,参照《非物质文化遗产保护法》第七条规定,县级以上地方人民政府文化主管部门具有提起诉讼的权利。

4.2 吸引资产权适用于具有集合性特征的吸引对象

如上所述,关于吸引资产权益分配的冲突产生于两个方面:1)广域性景观带来的旅游收益的分配问题;2)地方文化财产特别是传统知识、文化表达、非物质文化遗产的商业化开发导致财产权益受到侵害。从商业利用价值来看,普通的单个吸引物的吸引力通常不足以产生足够大的商业利益。特别是在边远的民族地区和乡村地区,为了克服距离产生的阻力,需要将若干具有自然、文化或历史属性的多个和多类吸引物有机地组合在一起,形成地域化的、具有集合性质的旅游景观,以提升吸引物的商业转化价值。正因如此,才导致有学者认为旅游吸引物存在概念模糊、内容不确定、价值主观性等问题,旅游吸引资产权从而无法作为实体权利在法律中得到确立^[9-10]。这一质疑又牵扯出两个问题:第一,概念的模糊性和价值的主观性能否否定吸引资产权作为法律权利的存在性和必要性^③;第二,集合性吸引物是否可以界定其权益归属。前者关系到立法的理念,后者涉及技术性问题。

笔者认为,理论的不完善不足以否定吸引资产作为实体权利在法律中得到确立的必要性。吸引资产权的实质是事或物因其吸引价值带来的商业

利益。其虽名为权利,实为利益,实质是将物品、活动、景观或其他文化对象的吸引力商品化和物化为其所有者的金融性财产。它是法律应当保护的合法利益。同样,价值的主观性也不足以否定吸引资产权利的存在性。诚然,吸引对象的吸引力大小具有一定的主观性,不同的人对相同事物、风景或文化对象的感受和价值判断存在差异,但价值主观性和个体差异性是所有无形资产的普遍特征。在公平市场上可根据市场交易的价格来公允地确定其价格^[8]。

虽然集合性质的旅游吸引对象的财产收益因其集合性而难以区分各组成部分的经济贡献,倘若某景观区域或某集合体在法律上可以被区分为若干个产权清晰的独立组成部分,则每个部分都可以成为这种财产权利的客体。这在我国的城市楼盘销售以及社区旅游实践中已有相当多的现实经验可遵循采纳。例如《阿者科计划》分红规则规定,乡村旅游发展所得收入3成归村集体旅游公司,用于公司日常运营,7成归村民。其中,归村民的分红再分4部分执行:传统民居保护分红40%,梯田保护分红30%,居住分红20%,户籍分红10%^[14]。再如,安徽省黟县西递村对村内224幢古民居实行“一户一档”登记,旅游收益按照各自房屋面积以及户籍人口数进行分配^[61]。只要构成集合性吸引物的各类对象的所有权属明确,那么吸引价值收益属于全体产权人所有,可通过协商、谈判、订立合同、许可等多种方式决定其收益分配。

4.3 地域/空间规则可用于界定集合性吸引资产的边界与权利主体范围

对集合性吸引对象的权利主体范围的限定,可采用地域/空间规则,以土地或场所的空间作为边界,将权利主体设定为遵循地域/空间规则或习惯、参与景观形成和维持文化活动以及创造的地域范围内的居民或具体吸引对象的提供者。笔者提出采纳地域/空间规则主要基于以下理由。

第一,从景观的角度,地域是文化理念生成的

①《中华人民共和国民法典》第一编总则第五章民事权利第123条规定了民事主体依法享有的知识产权包括:(一)作品;(二)发明、实用新型、外观设计;(三)商标;(四)地理标志;(五)商业秘密;(六)集成电路布图设计;(七)植物新品种;(八)法律规定的其他客体。

②兰州文化旅游.《兰州市旅游景区特许经营管理办法(试行)》印发 重大经营项目特许经营期限不超过30年[EB/OL].[2023-10-13]. lzbs.com.cn.

③关于概念的模糊性问题实则是研究者对吸引物概念的误解所造成,相关讨论可参见文献[7]和[8],此处不再赘述。

本源和哺育各种物质和非物质文化形式的载体。土地是形成人文景观和遗产,对访问者产生吸引力的底层逻辑。正如《宣言》所指出,文化是自然的延伸,“土地是土著文化的核心和基础”^[30];文化的“智力”方面不能与“物质”“自然”或“精神”元素分开。当地的生态环境、动植物资源、气候气象以及人们的管理实践知识和劳动投入,都是景观营造或吸引价值创造中不可分割的元素。

第二,各国对土地及其附属建筑的权属和空间边界的权属界定都非常清晰,可通过明确规定吸引资产的空间边界来确定其权利主体。我国于2023年4月已全面实现不动产统一登记,覆盖所有国土空间,从城市房屋到农村宅基地,从不动产到自然资源。此举为按照地域空间规则确立广域性吸引资产权奠定了坚实的法律和制度基础,但尚需在相关法律条文中进行补充说明或提供司法解释,将其单独析出,承认和保护这种收益性资产及其权属^[4,7-8]。在国际上,《宣言》也将土著人民土地权视为土著人权利体系中的核心和基础性权利,认为土著人土地权超越了物权概念,是土著人生存发展的基本权利^[30]。在许多有着殖民历史的西方国家,都为土著人民划出一部分供集体专有使用的土地(称为“保留地”),基本上相当于完全的土地所有权^[62]。即便吸引物属于展览或节事活动等人为类型,通常也具有较为清晰和明确的物理空间边界,而虚拟赛博空间的边界则更加明确,更加易于限制访问。

第三,公共遗产并非免费遗产。从观景的权利-义务关系出发,观景权不应惠及单纯享受景观“公共利益”或历史恩泽的所有人(见3.2节)。威尼斯向游客收取进城费即是遵循了此理。

吸引资产权超越知识产权的地方正是在于其对地方性社区集体权利的承认。吸引资产权将文化、习俗、活动等无形资产和土地、建筑、设施等有形资产紧密联系在一起,并强调创造、保护和发展当地公共吸引资产的集体责任。它既承认和维护社区文化财产的集体性,同时也保护个体重视的私权;它既适应于社区控制和集体管理,不过度强调私有化,又与知识产权制度所隐含的财产权利规范相吻合。例如阿者科村旅游收益中关于梯田分红规则规定,继续耕种梯田(水田)的农户,将取得全部梯田分红,一旦废耕或者改旱,视为自动放弃梯田分红;同样,其户籍分红规则规定,户籍在村且在村居住并为村里出义工的,才能获得居住分红^[14]。黟县西递村也制定了村民积分制考核方案,根据每个村民在资源保护和旅游发展过程中的日常表现进

行考核,年度考评得分与村民年终旅游分红挂钩^[61]。可见,将地域/空间原则作为确保吸引资产权公共性的公序,有助于以地域空间(如土著保留地)为基础开展地方知识和文化遗产保护,可为保护文化遗产和传承传统知识提供新的理念和模式。这一规则不仅有益于解决基于社区的旅游发展收益分配问题,而且对于保护土著人民传统知识和文化表达以及非物质文化遗产在商业化开发过程中的财产权利,具有特别重要的作用。

4.4 吸引资产权与知识产权在权能上互补兼容

吸引资产权和知识产权的共同之处在于:它们都涉及人类心灵创造的成果因其精神价值而产生的经济收益问题;侵权会造成所有权人或创作者在文化、精神和经济上的损失。但二者又存在重要的区别:知识产权代表的是一种永久创造的制度。创作人拥有永久创作权(精神权利)以及短暂保护期内的垄断权;而吸引资产权的最终指向是(国家、集体和私人的)永久所有权的制度。吸引资产权益的所有者不一定是创作者,但他们拥有所传承的或在此基础上进一步发展创造的吸引物,且无期限限制。当然,吸引资产权作为用益物权可以通过合同授权或其他约定方式将其出质,也可随吸引物所有权的转移而转移。

可见,吸引资产权与知识产权并非是竞争性的和相互替代的,而是兼容互补的。在知识产权的法律框架下,专利、版权、商标、地理标志等可以用于保护创作者或传统知识持有人的权益,防止他人在市场上混淆或损害其独特价值。我国《民法典》第三编第二分编第九章第600条规定,“出卖具有知识产权的标的物的,除法律另有规定或者当事人另有约定外,该标的物的知识产权不属于买受人”。在传统文化或知识要素或基于这两者的创新物无法获得知识产权保护的情况下,或在吸引对象因其集合性而难以确定产权主体的情况下,吸引资产权提供了另一可行的法律途径来保护这些集体所有的文化、知识和景观免受某些未经授权的商业使用的侵害,以确保权利主体的财产权得到尊重和保护。

设立吸引资产权的目的是提高作为吸引物的自然和文化景观,包括传统知识和表达的财产权益的法律确定性和清晰度。它赋予了权利人自由行使其意志的法定权利。无论是集体所有还是个体所有,基于地域/空间规则的具有用益物权性质的吸引资产权可赋予其所有者或用益物权人/托管人拥有其文化吸引资产及其数字孪生品的专有权利。

他们可以授权或阻止其他人利用其吸引物进行旅游开发,或用于数字复制以及其他文化或商业活动。由于财产权具有对世性,吸引资产在防范第三方的非法主张方面具有比知识产权以及合同债权更强的防御能力。

在西方有殖民扩张历史的国家,当涉及土著人民的传统知识和文化表达时,国家和土著社区关于所有权主张之间的潜在冲突尤为紧张^[63]。吸引资产作为财产权派生权益的理念与非西方认识论相契合,创造了新的类似于知识产权的权益保护机制。它与国家和国际立法要求实现土著对其遗传资源和相关传统知识的控制理念一致,并与西方的自由主义法律体系相兼容,可弥合西方和非西方社会关于知识治理的意识形态分歧,从而提供了基于本土情感和世界观的更加令人满意的政治、经济和法律解决方案。

4.5 吸引资产权的设立有助于发展和完善观景权

吸引资产权概念和权益归属的明确界定也可为进一步保护公民的观景权提供法制基础,有助于发展和完善环境权。21世纪以来,随着物质的日渐丰裕,良好的环境体验和审美享受被提上日程。F·吉伯特在《市镇设计》中讲到:“生活中的美不是事后思考的事,它是一种需要。……环境的秩序和美犹如新鲜空气对人的健康同样必要。”^[64]正是在社会需求的推动下,“环境权说”^①近年来迅猛发展,观景权(指公权性质)被列为与清洁空气权、清洁水权、日照权、通风权、安宁权等一样,属于公民环境权中的实体权利,并在某种程度上具有人身权性质,甚至有学者主张应该将其入宪加以保护^[58]。原因在于,被强制剥夺欣赏美景导致身心受损也应被归为一种人身损害。

我国现行法律并未明确承认单独的观景权。在物权法出台以前,我国对观景权纠纷的处理主要依据《民法通则》第83条对相邻关系的规定。然而,从相邻关系的法律本质来看,观景权并不属于相邻关系的范畴,而应该属于地役权^[57]。如果依据《物权法》第十四章中规定的地役权对观景权进行保护,也会带来实践中的问题。因为地役权属于用益物权,需经过登记才具有对世效力。在没有设立之前,观景权是不存在的,否则是对供役主体地役权的侵犯。

从互换利害关系出发,如果采纳地域空间规则为所有权人(供役方)设立了单独的吸引资产权,将

其权益独立出来加以保护,那么也就相当于从法律上认可了观景权或眺望权。这是由于,当吸引资产成为了产权人的财产权益,则产权人有义务根据历史条件维持特定的景观价值和精神价值。亦即,吸引物产权人履行义务是保障他人依法享受观景权的实现条件。反之,当他人(或用役方)要求依法享受观景权(或开发利用景观利益)时,也有义务支付相应的价款以补偿所有权人为维持和保护吸引物(遗产和文化)而投入的知识、劳动和金钱。由于观景权和吸引资产权相互依存,互为对应,从法律上承认吸引资产权,不仅有助于维持优美的环境,为公众提供景观利益,亦可助力文化遗产与活化,并且确保了权利义务相统一的原则,即:反对只享受权利(景观利益)而不承担义务(支付价款)的特权,同时也反对只承担义务(提供公共利益)而不享受权利(收益补偿)的歧视。

5 数字吸引资产及其产权归属

5.1 吸引物数字化

传统上,吸引力隐含或附着于其承载介质,人们无法将两者分离,因而其所有权人对其吸引资产可以保持一定程度的物理控制。消费者必须前往吸引物所在地才能体验并获得精神价值,由此才导致“旅游吸引物”概念的出现。数字技术使“直接存在的一切全都转化为一个表象”^[15]。云旅游、旅游直播以及虚拟现实、元宇宙等文旅消费新场景的出现使得消费者无需“异地”即可欣赏。尽管“旅游”在此情境下消失,但吸引物的吸引价值仍然可以通过在线方式得到呈现。无论是独特的地方景观还是其他文化财产,无论通过旅游、在地或在线方式,只要可以吸引消费者的注意力,就可以商业化利用成为可市场化估值的资产,即吸引资产。

图1展示了客观世界的吸引物在数字技术支持下转变成为数字孪生品并进而成为可被挖掘获得增值的数据资产^②的整个过程。首先,真实世界吸引物原型被记录、拍摄、转换,通过技术处理脱离其载体介质,成为用声音、文字、图像或影像整合而成的意象化景像,即原始吸引物的数字孪生品。这些数字孪生吸引物的原始数据集可被看做资源性数据资产。它们具有潜在的开发价值,经过确权并被

①环境权是指当地居民对周遭一切或自然或社会环境的一种排他支配权。

②数据资产指的是拥有数据权属(勘探权、使用权、所有权),有价值、可计量、可读取的网络空间数据集。

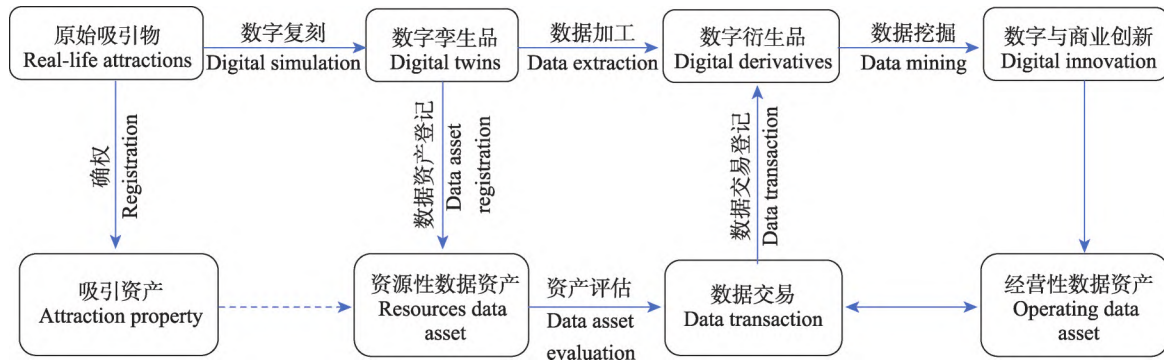


图1 原始吸引物数字化与资产数据化

Fig.1 The digitization of real-life attraction assets

挖掘和加工处理后可以被商品化为在市场上销售和流通的数字产品,如基于景观原型的元宇宙产品或游戏旅游软件,成为用益者的经营性数据资产。进一步地,这些可以直接在市场上作为商品流通的经营性数据资产还可被挖掘和利用、开发各类衍生品(含数字衍生品)和延展品,在线上线下市场上流通、交易或共享。

5.2 数字吸引资产权益归属

在吸引资产数据化的过程中,最为关键的一步是对资源性数据资产进行确权,为进一步的价值创造和数据资产的流通打下基础。从法律意义上而言,资产是特定主体所享有的可获得收益的现时权利,它可以是所有权、特许权、使用权、租赁权或这些权利的某种组合;资产所有权本身是无形的,但所有的资产却可以是有形的,也可以是无形的^[65]。如果我们承认阿者科景观在商业社会中的吸引价值,认可它是阿者科社区的文化财产,则当这些景观被记录、拍摄、转换为数字格式并进行商业化开发时,其实质是将阿者科社区的吸引资产加以数字化使用。此时,现实中的吸引资产将相应地转变为吸引物原型拥有者的数字资产。亦即,对吸引资产的数字化使用不能改变资产所有者的实质性权利。

数字阿者科只是阿者科的“拟像”。从产生源而言,吸引资产的数据集具有内生性,是对现实世界吸引物原型的属性、特征及其关系的描述和呈现,其吸引价值的来源并非数字阿者科公司。数字阿者科公司只是传递吸引价值的技术公司,实现将价值转移给受众。尽管这种数字化产品由数字阿者科公司制作,其生产传播技术会影响到价值的传递,但数字吸引物的价值来源是阿者科村民。因此,阿者科社区作为文化景观原型的所有人,享有

这批资源性资产的合法利益,包括拥有数据的自主决定权,可以自主决定对哪些景观或景观数据以何种条件进行共享,可以决定谁可以使用这些数据,也可以禁止用户和第三方使用收到的数据来开发与数据来源(阿者科)相竞争的产品,同时,也可以对数据进行挖掘、加工和创新使用,进一步参与到新兴的数字经济中。

吸引资产具有用益物权性质,需要通过登记以界定资产的权属。我国目前关于数据资产相关的登记制度^①正在完善之中^[66]。2022年12月,中共中央和国务院共同发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,提出探索数据产权结构性分置制度,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架^[67]。笔者建议,有条件发展线上数字化体验产品的各类文化和旅游机构积极申请数据资产登记。一方面可以为所拥有的数据资源或文化知识产权确权;另一方面基于数据要素的登记,可邀请专业机构来对该数据要素进行潜在价值的评估,即开展数据资产的评估,从而为获得进一步的加工使用(延展式创新)和进入数据产品(商品)流通交易市场提供依据。

需要注意的是,本文对吸引物数字资产权益的讨论局限于其数字孪生品的数据产权,这是因为数字孪生品只不过是现实人文景观或文化原型的数字复刻。从当前的线上数字景像呈现来看,无论是博物馆的“云展览”,还是景区“云旅游”或“云景观”,除了数字孪生品以外,还包括在其基础上发展

②数据资产登记是指对数据要素、数据产品的事物及其物权进行登记的行为,指经登记者申请,数据资产登记机构依据法定的程序将有关申请人的数据资产的物权及其事项、流通交易记录记载于数据资产系统中,取得数据资产登记证书,并供他人查阅的行为^[67]。

出来的衍生型、独立型产品。他们分别代表延展式数字创新和独立数字创作两种技术手段。吸引知识产权的设立有助于保护其数字孪生品的数据产权,关于数字延展式产品是否构成挪用滥用或侵权,需要进行专业判断;而独立数字创作品与本文的讨论无关。

6 研究结论与政策建议

伴随虚拟现实、元宇宙、云旅游等各种文旅消费新场景的出现,文化材料和文化景观的数字化如火如荼。以数字技术为凭借,各类档案文献、博物馆藏品、剪纸、武术、食物制作等非物质文化遗产纷纷走向数字化,云旅游、云展览、云景观体验日新月异。其中,不仅有各国出于保护目的而开展的公益行动,也有地方政府希望利用地方文化吸引物形成的数字资产进行商业化开发以吸引投资和刺激经济增长的政策鼓励,但更常见的是大量商业投资者意图通过“文化圈地”抢占文化高地以获得数字吸引资产的控制权。

虽然国际人权和知识产权框架建立了文化提供者对其传统知识和文化表达进行经济控制并从中受益的合法途径,但完全依靠国际公约解决所有权认定、利益分享和补偿等问题是不够的,在实践中也存在诸多困境。西方与非西方本体论与价值观的冲突,国际公约和国家管辖权之间的鸿沟,使得知识产权在应用于保护传统知识和文化遗产产生的商业收益时尤其成问题。随着越来越多的网络视频、数字音乐、文创企业利用数字文化资产的运营来获得收益,数字吸引资产的所有权和控制权的争夺变得愈发激烈。吸引物原型提供者、创作者与网络科技企业之间的冲突也日益紧张,亟须突破现有管理框架,以前瞻性的法律方式建立起保护和完善数字吸引资产的治理体系。

笔者认为,只有明晰了现实世界中的吸引对象的权益归属,才能为其数字化之后的数据资产确权奠定基础。在旅游吸引物权研究的基础上,结合注意力经济时代背景和数字社会发展现状,本文将旅游吸引物权拓展为吸引资产权的概念,并延伸至其数字孪生品的数据产权。从理论上剖析了知识产权的局限性及其与吸引资产权之间的关系,回应了研究者的质疑,并从吸引资产权与观景权形成互换性利害关系的角度对设立吸引资产权的必要性提出了新的论证,对吸引资产权的适用领域、应用原则、制度基础进行了剖析,最后对其数字衍生品的

数据产权归属进行了讨论,得到以下结论。

1)在注意力经济时代,地方文化以及景观所隐含或承载的吸引价值已经商业化为具有文化资产和经济资产双重属性的吸引资产。由于景观的广域性以及文化的集体创造特征,限制了使用专利和版权等知识产权工具作为保护吸引资产所有者财产权利主张的手段。吸引资产权制度的建立,不仅契合非西方社会人民关于文化财产集体所有的本体论和认识论,而且与现代国家正式法律制度和产权规范等实际情况相吻合,可以弥补知识产权制度框架的不足,与知识产权形成互补和兼容的文化财产保护体系。

2)相比知识产权,吸引资产权更具张力和包容性。由于采纳了地域/空间规则和集合性观念,吸引资产权可通过多重可协商关系灵活性构成,而不仅仅是排他性的专有权。它可以是多种权利和关系的嵌套或捆绑,包括订立合同出质、信托、隐性许可、特许经营等。同时,对吸引资产的管理以及对当地习俗和道德的遵守等都可以社会协议或惯例为前提,而不仅仅是知识产权框架下创作者的私有化行为。在法律上率先认可和承认吸引资产权,可为世界提供保护文化遗产和传统知识的中国方案。

3)吸引资产权有其适用条件和应用原则。从效率的角度,吸引资产权适用于在现有知识产权框架和所有权制度下因吸引价值的集合性而难以确定产权主体的情形,主要包括地域性景观以及地方性文化材料。无论吸引对象是私人所有、集体所有还是国家所有,只要吸引对象所有权界定清晰,则其权属可清晰界定。地域/空间规则有助于划定景观利益和文化财产的权利主体范围。这可以被视为确保吸引资产收益的重要原则,同时也规定了权利人/持有人的集体责任,有助于当地社区或权利人控制、管理和维护其社会文化资产的核心价值,而不仅仅是建立关于吸引资产的商业使用规则。中国式土地和物权制度以及土著人民集体所有的土地制度,也为地域/空间规则的实施奠定了现实可行的法律基础。

4)在数字使用方面,吸引物的去物质化和数字化并不意味着其权属关系的转移和变更。数字孪生吸引物所产生的经济收益仍然归属于其吸引物原型的产权人,除非数字采集者在此基础上进行了加工,创造出新的吸引价值。数字吸引资产权益保护的重点是数字复刻型的数字孪生品以及以其作为原型的衍生品的数据产权。理论上,数字采集者只能拥有技术支持费用和新增吸引价值带来的收

益权。

基于以上结论,本文提出如下管理政策建议。

1)吸引物实质上已经成为一种文化和经济资本形式。在商业现实中,对吸引力资源的控制和分配是由大型商业资本和权力主导的,而不是文化和景观生产过程本身。因此,吸引资产收益通常由商业主导者分配,日益增大的数字鸿沟和权力不平衡格局将加剧主导者和文化材料提供者的“不成比例的议价能力”。地方政府的强力介入对于保护当地民族和社区的文化财产非常重要。地方政府需要转变角色,从规划者、管理者转变为地方传统知识和文化的“托管人”“守夜人”,成为主导地方文化财产权属配置的主体,包括制定本行政区域内各类文化资源开放获取的条件,确保地方艺术、民间文学和文化作品在公开展示或出售时都已获得有关个人或集体授权,且明确标明归属地名称。

2)鉴于对地方文化和吸引物的数字化使用越来越普遍,地方政府应加快推动基于吸引物孪生品的数据资源产权的登记,建立类似招商引资项目集的文旅数字资源库,及时统计汇总各类数字吸引资产的“实物量”,从而为地方文旅资产进入数据产品(商品)流通交易市场提供便利,引导产业对数据资源的利用和保护。同时,也需要尊重数字技术合作方的协同作用,推动发展虚拟展示、智慧旅游、数字化体验产品等,为地方开创新的文化传承空间、新的文化体验方式以及新的文化传播业态提供服务。

3)吸引资产权不仅强调供给者的具体财产权益,也强调持有者及其后代为维护其价值而需要承担的义务。当地社区或权利人需要承担起作为吸引物的守护者和生产者的应有责任,积极承担相应的义务,维护和提升文化景观吸引价值,开展数字多媒体制作,将其文化财产转变为数字吸引资产,以记录、传播和振兴地方文化,同时确保集体成员对吸引价值的所有权享有公平收益。

4)从互换性利害关系出发,观景权与吸引资产权构成了一组权利-义务对应统一的关系。我国《环境保护法》目前主要采用“消极限权”的策略,以防止侵害为立法目的。现行法律对景观利益受益方(观景权)和供给方的财产权益(即吸引资产权)在法律上的保护力度都很一般。两者均未作为单独的权利加以保护。吸引资产权的提出可为观景权的设立提供启发,建议我国在未来《环境保护法》修订中采取“积极赋权”策略,将公权性观景权确立为公民环境权中的实体权利,最大限度地维护公众享受公共美景的权利,同时鼓励私权性景观的建

设,为民众提供更多的文化欣赏、旅游、娱乐和休闲机会,增加社会福祉,满足人民对美好生活的向往。

在数字文化经济新时代,文化与科技融合已经成为一个国家综合实力的展现。全球文化竞争格局不断升级,亟须制定新的原则,建立特殊权利制度来管理文化和各类吸引物的使用,以促进文化保护、文化创意和数字文化经济发展。从法律上承认吸引资产权并清晰界定其权益归属,可为文旅资源的开发利用和数字遗产、数字景观以及任何以数字形式呈现的文化吸引物提供产权基础,更好地应对未来数字社会中的相关财产争议。这不仅是推动文旅深度融合发展的需要,也是推动数字文旅产业有序发展的前提条件。率先推动吸引资产权的制度建设,可以成为中国对世界文化保护和传统知识治理的有益制度贡献之一。

参考文献(References)

- [1] DAVENPORT H T, BECK C J. *The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business*[M]. Brighton: Harvard Business Review Press, 2002: 15.
- [2] THROSBY D. *The Economics of Cultural Policy*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010: 88-105.
- [3] COOMBE R J. The expanding purview of cultural properties and their politics[J]. *Annual Review of Law and Social Science*, 2009(5): 393-412.
- [4] 左冰, 保继刚. 制度增权: 社区参与旅游发展之土地权利变革[J]. *旅游学刊*, 2012, 26(2): 23-31. [ZUO Bing, BAO Jigang. Institutional empowerment: Community participation and changes of land property rights in tourism development[J]. *Tourism Tribune*, 2011, 26(2): 23-31.]
- [5] NICHOLAS P G. Intellectual property issues[M]// SILBERMAN N A. *The Oxford Companion to Archaeology* (Vol. 2, the 2nd edition). Oxford: Oxford University Press, 2012: 106-109.
- [6] BROWN D, NICHOLAS P G. Protecting indigenous cultural property in the age of digital democracy: Institutional and communal responses to Canadian First Nations and Māori heritage concerns[J]. *Journal of Material Culture*, 2012, 17(3): 307-324.
- [7] 保继刚, 左冰. 为旅游吸引物权立法[J]. *旅游学刊*, 2012, 27(7): 11-18. [BAO Jigang, ZUO Bing. Legislating for tourist attractions rights[J]. *Tourism Tribune*, 2012, 27(7): 11-18.]
- [8] 左冰, 保继刚. 旅游吸引物权再考察[J]. *旅游学刊*, 2016, 31(7): 13-23. [ZUO Bing, BAO Jigang. Revisiting tourist attractions rights[J]. *Tourism Tribune*, 2016, 31(7): 13-23.]
- [9] 张琼, 张德森. 旅游吸引物权不可统一立法之辨析[J]. *旅游学刊*, 2013, 28(12): 90-96. [ZHANG Qiong, ZHANG Demiao. Analyses on tourist attractions rights cannot being legislated[J]. *Tourism Tribune*, 2013, 28(12): 90-96.]
- [10] 张琼, 张德森. 旅游吸引物权整体立法保护质疑[J]. *法治研究*, 2013(6): 84-89. [ZHANG Qiong, ZHANG Demiao. Question on the whole legislative protection of tourism attraction property right[J]. *Research on Rule of Law*, 2013(6): 84-89.]

- [11] 辛纪元, 曹务坤, 吴大华. 旅游吸引物权的表达与实践[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2014, 46(5): 111-115. [XIN Jiyuan, CAO Wukun, WU Dahua. Expression of the ownership of tourist attractions and the related practice[J]. *Journal of Yunnan Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition)*, 2014, 46(5): 111-115.]
- [12] 唐兵, 惠红. 民族地区原住民参与旅游开发的法律赋权研究——兼与左冰、保继刚商榷[J]. 旅游学刊, 2014, 29(7): 39-46. [TANG Bing, HUI Hong, A study on legal empowerment on indigenous people participation in tourism development in ethnic areas: A discussion with ZUO bing, BAO Jigang[J]. *Tourism Tribune*, 2014, 29(7): 39-46.]
- [13] 王维艳. “阿者科计划”的个体特殊性超越与边界约束——布迪厄社会实践理论视角[J]. 旅游导刊, 2023, 7(1): 41-61. [WANG Weiyan. Transcending the individual particularity and boundary constraint of Azheke Plan: A Bourdieusian perspective on social practice[J]. *Tourism and Hospitality Prospects*, 2023, 7(1): 41-61.]
- [14] 保继刚, 杨兵. 旅游开发中旅游吸引物权的制度化路径与实践效应——以“阿者科计划”减贫试验为例[J]. 旅游学刊, 2022 37(1):18-31. [BAO Jigang, YANG Bing. Institutionalization and practices of the “rights to tourist attractions” (RTA) in “Azheke Plan”: A field study of tourism development and poverty reduction[J]. *Tourism Tribune*, 2022, 37(1): 18-31.]
- [15] 居伊·德波. 景观社会[M]. 张新木, 译. 南京: 南京大学出版社, 2017: 3. [DOBORD E G. *The Society of the Spectacle*[M]. ZHANG Xinmu, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2017: 3.]
- [16] VÉZINA B. Curbing cultural appropriation in the fashion industry with intellectual property[C]//*The Centre for International Governance Innovation*. CIGI Papers No. 213, 2019. <https://www.cigionline.org/static/documents/documents/paper%20no.213.pdf>.
- [17] PIETROBRUNO S. Between narratives and lists: Performing digital intangible heritage through global media[J]. *International Journal of Heritage Studies*, 2014, 20 (7/8): 742-759.
- [18] International Labor Organization. *Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 (No. 169)* [EB/OL]. [2023-06-25]https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169.
- [19] ANAYA S J. International human rights and indigenous peoples: The move toward the multicultural state[J]. *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 2004, 21(1): 13-61.
- [20] NICHOLAS P G, BELL C, BANNISTER K, et al. Intellectual property issues in heritage management[J]. *Heritage Management*, 2009(2): 261-286.
- [21] AGUILAR G. Access to genetic resources and protection of traditional knowledge in the territories of indigenous peoples[J]. *Environmental Science & Policy*, 2001, 4(4-5): 241-256.
- [22] BROWN M F. Can culture be copyrighted?[J]. *Current Anthropology*, 1998, 3(2): 193-222.
- [23] FREDRIKSSON M. Dilemmas of protection: Decolonising the regulation of genetic resources as cultural heritage[J]. *International Journal of Heritage Studies*, 2021, 27(7): 720-733.
- [24] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mexico City declaration on cultural policies: Final report[EB/OL]. [2023-06-25]. CLT/MD/1. 1982. *UNESCO World Conference on Cultural Policies*, Mexico City, 26 July -6 August 1982. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000052505>.
- [25] COOMBE R J, TURCOTTE J F. Indigenous cultural heritage in development and trade: Perspectives from the dynamics of cultural heritage law and policy[M]//GRABER C, KUPRECHT K, LAI J. *International Trade in Indigenous Cultural Heritage*. Cheltenham: Edward Elger, 2012: 211-236.
- [26] NIEC H. Cultural rights and wrongs: A collection of essays in commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights[J]. *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 1998, 5(12): 13-34.
- [27] United Nations. *Convention on Biological Diversity 1992*[EB/OL]. [2023-06-25]. <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>.
- [28] World Intellectual Property Organization. *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)*[EB/OL]. [2023-06-25]. WIPO/GRTKF/IC/3/8. 2002. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_3/wipo_grtkf_ic_3_8.pdf.
- [29] NICHOLAS G, BELL C, COOMBE R, et al. Intellectual property issues in heritage management[J]. *Heritage Management*, 2010, 3(1): 117-147.
- [30] United Nations. *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*[EB/OL]. [2023-05-19]. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf. 2003.
- [31] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Charter on the Preservation of Digital Heritage*[EB/OL]. [2023-11-23]. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/charter-preservation-digital-heritage>.
- [32] BROWN M F. Who owns native culture?[J]. *Journal of Latin American & Caribbean Anthropology*, 2006, 11(1): 242-244.
- [33] LESSIG L. *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*[M]. New York: Penguin, 2004: 15.
- [34] UNESCO. *Charter on the Preservation of Digital Heritage*[EB/OL]. [2023-12-20]. <https://en.unesco.org/about-us/legal-affairs/charter-preservation-digital-heritage>.
- [35] MACMILLAN F. The protection of cultural heritage: Common heritage of humankind, national cultural ‘patrimony’ or private property?[J]. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 2013, 64(3): 351-364.
- [36] HENNESSY K. Cultural heritage on the web: Applied digital visual anthropology and local cultural property rights discourse [J]. *International Journal of Cultural Property*, 2012, 19: 345-369.
- [37] SHIVA V. Bioprospecting as sophisticated biopiracy[J]. *Signs*, 2007, 32(2): 307-313.
- [38] KLOPPENBURG J. *First the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology*, 1492—2000[M]. Madison: University of Wisconsin Press. 2004: 186.
- [39] NOYES J E. The common heritage of mankind: Past, present, and future[J]. *Denver Journal of International Law and Policy*, 2012, 40: 447-471.
- [40] POSEY D A. Commodification of the sacred through intellectual property rights[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2002, 83 (1/2): 3-12.
- [41] NICHOLAS G P, BANNISTER K P. Copyrighting the past?

- Emerging intellectual property rights issues in archaeology[J]. *Current Anthropology*, 2004, 45(3): 327-350.
- [42] COOMBE R J, BAIRD M. The limits of heritage: corporate interests and cultural rights on resource frontiers[M]// LOGAN W, CRAITH M N, KOCKEL U. *A Companion to Heritage Studies*. Maitland: John Wiley & Sons, 2015: 337-354.
- [43] PIGLIASCO G C. Intangible cultural property, tangible databases, visible debates: The Sawau project[J]. *International Journal of Cultural Property*, 2009, 16(3): 255-272.
- [44] STEVENSON M G, WEBB J. Just another stakeholder? First nations and sustainable forest management in Canada's boreal forest[M]// BURTON P J, MESSIER C, SMITH D W, et al. *Towards Sustainable Forest Management in Canada's Boreal Forest*. Ottawa: NRC Research Press, 2003: 65-112.
- [45] United Nations Development Programme. *Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: A Practice Note*[EB/OL]. [2023-05-19]. <https://www.undp.org/publications/access-genetic-resources-and-benefit-sharing-theory-practice-under-nagoya-protocol>.
- [46] 张琼, 张德森. 再论旅游吸引物的法律属性[J]. *旅游学刊*, 2016, 31(7): 24-31. [ZHANG Qiong, ZHANG Demiao. Discussion on legal rights of tourist attractions[J]. *Tourism Tribune*, 2016, 31(7): 24-31.]
- [47] HIGUERAS A, WOODS J. Indigenous intellectual property issues in archaeology[M]// SMITH C. *Encyclopedia of Global Archaeology*. New York: Springer, 2016: 3805-3814.
- [48] World Intellectual Property Organization. Convention establishing the world intellectual property organization [EB/OL]. [2023-06-25]. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_250.pdf.
- [49] HELFER L, AUSTIN G. Indigenous peoples' rights, and intellectual property[M]// HELFER L R, AUSTIN G W. *Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011: 432-502.
- [50] KRISTEN A, CARPENTER S, KATYAL K, et al. Clarifying cultural property[J]. *International Journal of Cultural Property*, 2010, 17: 581-598.
- [51] World International Property Organization. Consolidated analysis of the legal protection of traditional cultural expressions/expressions of Folklore[EB/OL]. [2023-12-20]. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/785/wipo_pub_785.pdf.
- [52] HARRISON S. From prestige goods to legacies: Property and the objectification of culture in Melanesia[J]. *Comparative Study of Society and History*, 2000, 42(3): 662-679.
- [53] NICHOLAS G P. Protecting indigenous heritage objects, places, and values: Challenges, responses, and responsibilities[J]. *International Journal of Heritage Studies*, 2021, 28(33): 400-422.
- [54] OBERTHÜR S, RABITZ F. The role of the European union in the Nagoya protocol negotiations: self-interested bridge building [M]// OBERTHÜR S, ROSENDAL G K., *Global Governance of Genetic Resources: Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol*. London & New York: Routledge, 2014: 79-95.
- [55] 张进福. 物之序: 从“旅游资源”到“旅游吸引物”[J]. *旅游学刊*, 2021, 36(6): 45-59. [ZHANG Jinfu. From “tourism resource” to “tourist attraction”[J]. *Tourism Tribune*, 2021, 36(6): 45-59.]
- [56] Council of Europe. European Landscape Convention and reference documents [EB/OL]. [2023-07-14]. <https://rm.coe.int/CoERMPu-blicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f80c6>.
- [57] 顾梦婧. 从各国景观诉讼判例来看对景观利益的保护[J]. *上海法学研究*, 2022(1): 55-61. [GU Mengjing. The protection of landscape interests from the case of landscape litigation in several countries[J]. *Shanghai Legal Studies*, 2022(1): 55-61.]
- [58] 赵晓舒. 解析“眺望权”与“观景权”的有关法律问题[N]. *法制日报*, 2013-05-29(012). [ZHAO Xiaoshu. Analysis of the relevant legal issues of the “right to watch” and the “right to enjoy landscape”[N]. *Legal Daily*, 2013-05-29 (012).]
- [59] 中共中央编译局. 马克思恩格斯全集(第31卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1998: 349. [The Compilation and Translation Bureau of the CPC Central Committee. *The Complete Works of Marx and Engels (Vol. 31)* [M]. Beijing: People's Publishing House, 1998: 349]
- [60] WANG Y, ZHAO L, SOBKOWIAK L. Impact of urban landscape and environmental externalities on spatial differentiation of housing prices in Yangzhou city[J]. *Journal of Geographic Science*, 2015, 25(9): 1122-1136.
- [61] 马思伟. 传承徽韵文化 创新旅游发展——安徽西递的“最佳旅游乡村”发展之路[EB/OL]. [2023-07-14]. https://www.mct.gov.cn/whzx/qgwhxxlb/ah/202112/t20211210_929734.htm. [MA Siwei. Inheriting Huiyun culture and innovating tourism development—The development road of “Best Tourism Village” in Xidi, Anhui province[EB/OL]. [2023-07-14]. https://www.mct.gov.cn/whzx/qgwhxxlb/ah/202112/t20211210_929734.htm.]
- [62] Australia Queensland Government. *The History of Aboriginal Land Rights in Australia (1800s—1980s)*[Z]. Queensland Studies Authority, Res 006. 2007: 1-8. https://www.qcaa.qld.edu.au/downloads/approach2/indigenous_res006_0712.pdf.
- [63] 常本照树, 铃木敬夫, 吕艳滨, 译. 土著人民的文化与知识产权研究[J]. *太平洋学报*, 2009(4): 22-35. [MITSUMOTO T, SUZUKI K. LYU Yanbin, trans. A study on the culture and intellectual property rights of indigenous peoples[J]. *Pacific Journal*, 2009 (4): 22-35.]
- [64] F·吉伯特. 市镇设计[M]. 程里尧, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1983: 27. [GIBBERD F. *Town Design*[M]. CHENG Liyao, trans. Beijing: China Architecture and Architecture Press, 1983: 27.]
- [65] 黄申. 资产概念之法学研究[J]. *审计与经济研究*, 2006(1): 55-58. [HUANG Shen. Legal research on asset concept [J]. *Audit and Economic Research*, 2006(1): 55-58.]
- [66] 上海数据交易所有限公司. 全国统一数据资产登记体系建设白皮书[R]. 2022: 61. [Shanghai Data Exchange Co. LTD. *White Paper on the Construction of a National Unified Data Asset Registration System*[R]. 2022: 61.]
- [67] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见[EB/OL]. [2023-06-27]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm. [The Central People's Government of the People's Republic of China. Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and The State Council on building a data basic system to better play the role of data elements[EB/OL]. [2023-06-27]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm.]

From Landscape to Spectacle: A Further Discussion on the Attraction Property Rights in the Digital Age

ZUO Bing

(School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: In the era of the attention economy, traditional culture and landscape have been commercialized to create an attraction asset with both cultural and economic attributes. Owing to the intrinsic nature of collectively creating traditional culture and landscape, the law of intellectual property rights is limited when protecting the cultural property rights of indigenous holders. With the digitalization of cultural attractions, conflicts arise regarding who has the right to control and distribute earnings from the commercial use of cultural and tourist attractions. There is an urgent need to establish a new governance system to protect the property rights of cultural asset holders.

Following a review of international research progress and related disputes about protecting cultural property rights, this study analyzes the reasons for the legal framework of intellectual property rights being limited when protecting collectively created indigenous cultural assets. This paper extends the concept of tourism attraction property rights into a more extensive concept of attraction property rights; it clarifies the complementary relationship between attraction property rights (APRs) and intellectual property rights. This study then examines the necessity for legislation, practical feasibility, and importance when establishing APRs from the perspective of the interchangeable interest relationship between APRs and the rights to watch and enjoy landscapes. From the above analysis, this paper presents the conditions, principles, and institutional basis for creating and applying APRs. Finally, it discusses the data ownership issues of real attractions' digital twins and advocates strong local government involvement to protect indigenous cultural property. Local governments need to change their roles from administrators and planners to custodians and promoters of local traditional knowledge and culture property; they should facilitate the registration and circulation of digital heritage assets.

This study expands the concept of tourist APRs and contributes to a deeper understanding of the applicable conditions, principles, and institutional advantages of APRs. It provides a legal solution for dealing with property disputes when protecting traditional knowledge and culture heritage as well as with relevant data property disputes in a future digital society. It thus helps to promote the integration of culture and tourism toward forming an institutional basis for the development of digital culture and tourism in an appropriate manner. Legislating for APRs in China could make a positive institutional contribution to the world with respect to cultural protection and knowledge governance.

Keywords: cultural property; attraction property; intellectual property; the right to watch and enjoy landscapes; digital simulation; data asset

[责任编辑:吴巧红;责任校对:周小芳]